

1501016-21.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: CECÍLIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... em nenhum momento, a prática do crime de tráfico pelo acusado foi favorecida pela situação de calamidade pública atualmente vivenciada no país, não podendo, portanto, ser considerada para o fim de agravar a pena. Veja-se a respeito:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (16,8 G DE COCAÍNA E 35,3 G DE MACONHA). FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501016-21.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501016-21.2021.8.26.0537 2021/000801

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO FRANCO JUNIOR

Juiza de Direito: Dra. CECILIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Vistos.

FÁBIO FRANCO JUNIOR, qualificado a fls. 30, foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", cc. da Lei nº 11.343/06 c.c artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, porque, no dia 19 de maio de 2021, por volta das 10h35min, durante a vigência de "Estado de Calamidade Pública" (Decreto Estadual nº 65.502/21), trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 10 (dez) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso aproximado de 5,0 gramas e 34 (trinta e quatro) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso aproximado de 121,0 gramas, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Dispensada audiência de custódia, em razão da Pandemia de COVID-19, com base do comunicado da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo editado em 17/03/2020, proferiu-se decisão convertendo a prisão em flagrante do réu e do investigado Maick em prisão preventiva (fls. 86/88). Todavia, após a distribuição do processo, este Juízo proferiu decisão (fls. 102/103) em que relaxou as prisões, substituindo-as por medidas cautelares diversas.

Alvarás de soltura expedidos (fls. 104/106 e 107/109) e devidamente cumpridos (fls. 126/129 e 130/133).

Foi determinada a notificação do réu Fábio, após oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, sendo na mesma ocasião determinado o arquivamento do

procedimento investigativo com relação a Maick, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da lei 11.343/06, e com relação a Fábio, apenas no tocante ao crime previsto no artigo 35 da referida lei.

O réu foi notificado (fls. 165) e apresentou defesa prévia às fls. 173/174.

A denúncia foi recebida em 11 de agosto de 2021 (fls. 176/177).

O réu foi citado (fls. 222).

No dia 14/03/2022, realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento por meio telepresencial nos termos do Comunicado CG nº 284/2020 e resolução 329/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas e foi o réu interrogado, prosseguindo-se com os debates orais da acusação e defesa.

Em alegações finais, a D. Promotora de Justiça requereu, em apertada síntese, a procedência do pedido, condenando-se o réu nos termos da denúncia, posto que a materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovados. Aponta que a confissão do réu está em harmonia com a prova produzida em Juízo e com o quanto por ele dito em sede policial, por ocasião de sua prisão. Ressalta que mostra-se irrelevante o fato de não ter sido visto qualquer ato de comércio das drogas, posto que o tipo penal do artigo 33 da lei 11.343/06 é misto alternativo. Quanto à dosimetria, não se opõe à fixação da pena base no mínimo legal. Requer seja reconhecida a agravante pela prática do crime durante o estado de calamidade pública, compensando-se com a atenuante da confissão espontânea. Requer seja afastada a causa de redução de que trata o artigo 33, §4º da lei 11.343/06, por haver indicações de que o réu tem se dedicado à traficância. Pede, ainda, que seja fixado regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Requer, ao final, seja decretado o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu, intimando-se o investigado Maick para que faça o levantamento do dinheiro que trazia consigo.

A D. Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ante a fragilidade do acervo probatório. Aponta que os testemunhos dos policiais devem ser recebidos com reservas, por ter ele interesse em justificar suas ações em razão da função que exercem. Ressalta, por outro lado, que a confissão do acusado não se presta isoladamente a fundamentar a prolação de sentença condenatória, mas deve estar aliada a outros elementos de prova, para tanto. Subsidiariamente, em caso de condenação, pede a fixação da pena base no mínimo legal, por serem favoráveis as circunstâncias judiciais e tratar-se de réu primário. Na segunda etapa, pede seja afastada a agravante de que trata o artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, e que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, judicial e extrajudicial. Na última fase, requer a aplicação do redutor de que trata o artigo 33, §4º da lei 11.343/06, em seu patamar máximo, por não haver indicação de que se dedique a atividades criminosas ou pertença a organização criminosa. Pleiteia ainda a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena. Por fim, requer seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Após, os autos vieram conclusos para prolação de sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais. Ausentes nulidades a sanar ou preliminares a analisar, passo ao mérito.

O conjunto probatório constante nos autos demonstra a veracidade dos fatos narrados na denúncia, com a necessária segurança e certeza, para que seja julgado procedente o pedido condenatório.

A materialidade delitativa restou sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 13/17), auto de exibição e apreensão (fls. 26/27), laudo de constatação (fls. 19/21), fotografias (fls. 22/25) laudo de exame químico-toxicológico (fls. 154/156) e pela prova oral.

Também a autoria restou devidamente comprovada. Senão vejamos.

Ao ser ouvido em Juízo, o réu confessou a prática do crime, dizendo que as drogas de fato lhe pertenciam; a quantidade específica não se recorda. O indivíduo que estava com ele e foi abordado era usuário. O dinheiro apreendido com ele era produto da venda de drogas; as anotações também lhe pertenciam. Não conhecia os policiais que o abordaram, antes dos fatos.

A confissão do réu, ademais, foi corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Com efeito, em depoimento bastante seguro prestado a este Juízo, a testemunha João Batista Manuel Júnior, policial militar, afirmou que estavam em patrulhamento ele e seu colega Carlos, quando entraram em uma esquina da Rua Barão de Tamaragi, local conhecido de tráfico de drogas, e se depararam com o réu e um outro indivíduo. Saíram em perseguição deles e os abordaram um dos quais trazia a quantia de R\$ 150,00 e R\$ 98,00 em notas trocadas e algumas moedas, e um pacote por dentro das vestes, com drogas em porções fracionadas, a saber, maconha e cocaína, segundo se recorda, sem absoluta certeza no tocante às espécies. O réu e Maick disseram que estavam traficando e que, ao avistaram a viatura, saíram correndo. Foram também encontrados celular e pertences pessoais. Além do réu o do outro indivíduo que foi abordado, havia outras pessoas no local. Disse que costuma realizar abordagens similares no local. Não se recorda de haver anotações do tráfico. Novamente indagado, afirmou que um dos indivíduos que foram abordados disse que estava traficando, enquanto o outro estava com o dinheiro.

No mesmo sentido, a testemunha Carlos Alberto Gonçalves Junior, também policial militar, narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, que entrou na Rua dos Imigrantes, quando indivíduos correram pela barão de Uruguaiana e entraram na Barão de Caramagi. Lograram abordar 02 dos 03 indivíduos que estavam em fuga, e no momento da revista a droga foi encontrada nas vestes do acusado. Não se recorda da quantia de dinheiro encontrada com o réu e também com o outro rapaz, que alegou que havia apenas ido comprar drogas. Com o réu Fábio também foram localizadas as anotações referentes à contabilidade do tráfico. No momento da abordagem, o réu disse que as drogas não eram dele. Segundo se recorda, com o réu foram encontradas 10 porções de maconha e 10 porções de cocaína. Não conhecia o réu antes dos fatos

Cabe ressaltar, nesse passo, que as palavras dos policiais, que atuaram de maneira tão direta, não podem ser relevadas ou consideradas suspeitas apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando prestam contas de suas diligências.

Por outro lado, é plenamente compreensível o fato de nenhuma pessoa estranha aos quadros policiais ter sido arrolada para testemunhar em desfavor do réu, porque é sabido que casos de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes, a maioria das pessoas evita servir como testemunha, imperando nas comunidades verdadeira "lei do silêncio", temendo sofrer represálias.

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sequer conheciam e que sabem ser inocentes.

Assim, a credibilidade do testemunho dos policiais não pode ser afastada.

Dessa forma, constata-se que no dia dos fatos as testemunhas policiais estavam em patrulhamento pela região dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando avistaram o réu, o investigado Maick e um outro indivíduo em atitude suspeita, e puseram-se a persegui-los, com vistas a efetuar a abordagem. Durante a perseguição, Fábio e Maick foram alcançados e abordados. Com o réu foram localizados os entorpecentes apreendidos nestes autos, de natureza diversa e embalados em dezenas de porções individualizadas, a saber, 10 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso aproximado de 5,0 gramas e 34 invólucros plásticos contendo maconha, com peso aproximado de 121,0 gramas. Com Fábio também foi localizada a quantia de R\$ 98,50 e um papel, aparentemente contendo anotações referentes à contabilidade do tráfico (fls. 160/162). Nada de ilícito foi encontrado na posse de Maick. O réu, por seu turno, confessou tanto em sede policial, como também em Juízo, a prática do crime, confirmando que estava traficando, que as drogas que estavam com ele lhe pertenciam, e que o dinheiro do qual estava em posse era produto da venda de drogas. Assim, restou bem caracterizada a prática do crime de tráfico de entorpecentes, mostrando-se impossível, por consequência, a absolvição por insuficiência de provas.

Passo, deste modo, à dosimetria da pena, de forma individualizada, com observância

ao princípio da humanidade, nos termos do artigo 5º, inciso XLVI da Constituição Federal de 1988 e artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

Considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta maus antecedentes (fls. 188/193 e 212/213). Culpabilidade normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta. Assim, fixo a pena-base no piso legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. O dia-multa será à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais do réu.

Na segunda fase, trata-se de réu primário (fls. 188/193 e 212/213). Não observo a presença de circunstâncias agravantes que devam ser consideradas. Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual, todavia, não se presta a reduzir a pena já fixada no mínimo legal, conforme dispõe a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Consigno que, em nenhum momento, a prática do crime de tráfico pelo acusado foi favorecida pela situação de calamidade pública atualmente vivenciada no país, não podendo, portanto, ser considerada para o fim de agravar a pena. Veja-se a respeito:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (16,8 G DE COCAÍNA E 35,3 G DE MACONHA). FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE LIMITES LEGAIS MÁXIMOS E MÍNIMOS. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTES E ATENUANTES. ART. 61, II, J, DO CP. CALAMIDADE PÚBLICA. CONTEXTO DE PANDEMIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. 1. Quando a quantidade ou a variedade da droga não é significativa, não há falar em exasperação da pena-base, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade. 2. A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para prática do delito. 3. O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige que o paciente seja primário e de bons antecedentes, condição essa não preenchida pelo paciente. 4. Ordem parcialmente concedida para redimensionar a pena a 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 530 dias-multa, à razão mínima, pelos fundamentos declinados." (HC 654.255/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 07/06/2021)

Na terceira fase, reconheço a causa de diminuição de que trata o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, já que o réu é primário e sem antecedentes, não havendo demonstração de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, não podendo ser considerados para esse fim eventuais processos ainda em tramitação, pois não há notícia do trânsito em julgado nestes autos. Diante disso, reduzo a reprimenda em 2/3, alcançando, assim, o montante de 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, tornando-a definitiva por não encontrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável.

O regime inicial de cumprimento será o ABERTO, tendo em conta a primariedade do acusado, as circunstâncias favoráveis e o montante de pena aplicado, revelando-se suficiente à prevenção e repressão do crime. Ressalto, aliás, a tendência de nossos Tribunais Superiores no sentido de que o tráfico em sua forma privilegiada (§ 4º do artigo 33) não é considerado como hediondo e, bem por isso, se as demais circunstâncias do caso concreto não evidenciam a necessidade de fixação de regime rigoroso, possível a fixação de regime mais brando.

Impossível, entretanto, a substituição da pena, uma vez que insuficiente à repressão e prevenção do crime, especialmente em razão da diversidade de drogas apreendidas.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o réu FÁBIO FRANCO JUNIOR à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, e pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Como respondeu solto a este processo, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois não estão presentes os requisitos necessários à decretação de sua

prisão cautelar.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, observando-se o disposto no artigo 4º, §, 9º, "a", da Lei Estadual 11.608/03 e artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, que não abrangem valores eventualmente já depositados nos autos.

Caso não haja recurso desta sentença, oficie-se para destruição das amostras do entorpecente guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº

11.343/06, cabendo ressaltar que por ocasião da prolação da decisão que converteu a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls. 86/89) já houve determinação de destruição do entorpecente, reservando-se apenas o necessário à realização do laudo definitivo. Oficie-se também para destruição da sacola plástica e da folha de papel apreendidas (fls. 26/27)

Com relação à quantia de R\$ 98,50 apreendida em poder de Fábio (fls. 26/27 e 121), decreto seu perdimento em favor da União. Preceda-se conforme as determinações do artigo 63 da Lei de Drogas. Deverá ser dada a mesma destinação à quantia de R\$ 150,00 apreendida em poder de Maick, caso não haja pedido de restituição no prazo de 90 (noventa) dias contados do trânsito em julgado.

Sentença não publicada em audiência. Publique-se, intinem-se.

Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA